



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 03

MATERIAL DO PROFESSOR

8.2- Requisitos:

a) Ordem JUDICIAL motivada

ADVERTÊNCIA: o delegado NUNCA foi legitimado a determinar incomunicabilidade

b) Prazo de 3 dias;

c) Acesso do ADVOGADO.

8.3- Filtro constitucional- o art. 136, § 3º, IV, CF, tratando do ESTADO DE DEFESA, inadmite a incomunicabilidade. Logo, por interpretação lógica, o art. 21 do CPP não foi recepcionado.

ADVERTÊNCIA: não há incomunicabilidade aos sujeitos submetidos ao RDD- regime disciplinar diferenciado (art. 52 LEP).

9- Indiciamento

9.1- Conceito: indiciar significa convergir a investigação em face de determinada pessoa, ultrapassando a mera POSSIBILIDADE para um juízo de PROBABILIDADE.

9.2- Legitimidade- cabe ao DELEGADO DE POLÍCIA, no bojo da investigação policial, promover o indiciamento, não se submetendo a requisições de magistrados ou membros do MP para indicar esta ou aquela pessoa (art. 2º, § 6º, Lei 12.830/013).

9.3- Momento- não há na lei um marco para que o indiciamento seja promovido. Logo, segundo a DOUTRINA, o indiciamento deve ocorrer assim que possível, usualmente após a oitiva do suspeito.

Obs.1. Aquele sujeito que teve uma prisão cautelar decretada, bem como outra medida pessoal, presume-se indiciado.

Obs.2. O sujeito que já é réu em processo criminal, não será indicado em IP superveniente por fato que já objeto do processo. Se isso ocorrer, há violação ao “non bis in idem”, de forma que caberá um HC para trancar o IP.

Obs.3. Tal qual ocorre com o IP, o indiciamento é também DISPENSÁVEL. Logo, o sujeito pode ser denunciado sem ter sido previamente indiciado.

9.4- Requisitos- pressupomos despacho motivado, mediante análise técnico-jurídica, apontando os indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração (art. 2º, § 6º, Lei 12.830/013).

9.5- Classificação:

a) Indiciamento DIRETO- é aquele promovido na presença do sujeito.

b) Indiciamento INDIRETO- é aquele realizado quando o indivíduo não está presente.

c) Indiciamento coercitivo- é aquele proveniente da concretização do flagrante delito.

d) Indiciamento COMPLEXO- é aquele que necessita de prévia deliberação do Tribunal competente, já que o investigado goza de foro por prerrogativa de função.

9.6- Afastamento do funcionário público- o art. 17-D da Lei 9.613/98, contempla o afastamento do funcionário público indicado por lavagem que se valeu da função para promover o delito.

ADVERTÊNCIA: como o afastamento funcional é previsto no art. 319, VI, CPP, detro da cláusula de reserva de jurisdição, o STF declarou a inconstitucionalidade da previsão encampada na Lei de Lavagem, tendo o afastamento força administrativa, por ato do delegado (ADI 4.911/DF).

9.7- “Menor”- o CPP rotula os sujeitos entre 18 e 21 anos incompletos como “menores”, pois no nascimento do Código, o Código Civil da época os considerava relativamente capazes, em que pese possuírem capacidade penal.

Conclusão1. O art. 5º do atual CC os considera ABSOLUTAMENTE CAPAZES.

Conclusão2. O art. 15 do CPP, exigindo a nomeação de curador por força da faixa estaria encontra-se TACITAMENTE REVOGADO.

Conclusão3. Teremos a nomeação de curador em razão de eventual doença mental, com a instauração de incidente de insanidade (art. 3º-B, XIII c/c art. 149, § 2º, CPP).

9.8- Limitações:

a) Os membros do MP não serão indiciados pela polícia judiciária (art. 41, II, Lei 8625/93).

b) O membros da magistratura não serão indiciados pela polícia judiciária (art. 33, parágrafo único, LC 35/79).

c) Para as demais autoridades com foro por prerrogativa, dependemos de deliberação do Tribunal competente.

d) IMPO- usualmente não detectamos indicamento no TCO, que simboliza um registro simplificado que será encaminhado imediatamente ao juizado (art. 69, Lei 9099/95).

9.9- Desindiciamento

a) Conceito: significa a reversão do indiciamento, com o reapontamento da investigação.

ADVERTÊNCIA: o desindiciamento NÃO CARACTERIZA ou se confunde com o arquivamento do IP, que é defeso ao delegado (art. 17, CPP).

b) Modalidades:

b.1) Desindiciamento VOLUNTÁRIO- é aquele promovido pela autoridade policial no curso da investigação.

b.2) Desindiciamento COACTO- é aquele decorrente do êxito do HC impetrado para TRANCAR a investigação.

10- Procedimento:

10.1- 1º ETAPA- início- o IP é deflagrado por meio de uma PORTARIA.

Obs. O juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de toda e qualquer investigação (art. 3º-B, IV, CPP).

I- Conceito: é a peça escrita que demarca o início do IP.

II- Conteúdo:

- fato a ser investigado;
- envolvidos;
- diligências que devem ser imediatamente cumpridas;
- desfecho: determinação de instauração do IP.

III- Substituição- algumas peças podem funcionar como portaria, a exemplo do auto de flagrante ou da requisição do MP para a instauração do IP.

Obs. Notícia crime:

a) Conceito: é a comunicação da ocorrência de uma infração a autoridade com atribuição para agir.

b) Legitimados:

b.1) Destinatários:

i) Delegado

Obs. Postura:

- instaurar o IP;
- deflagrar uma VPI (verificação prévia da infração);
- negar a instauração do IP, entendendo que inexistente infração a apurar

Conclusão: o ato desafia RECURSO ADMINISTRATIVO ao Chefe de Polícia (art. 5º, § 2º, CPP).

ii) MP

Obs. Postura:

- requisitar a instauração de IP (art. 5º, II, CPP);
- instaurar um PIC (procedimento investigativo criminal);
- promover o arquivamento da peça de informação, ao entender que inexistente crime a apurar (art. 28, CPP);
- havendo JUSTA CAUSA, é possível a imediata oferta da denúncia, já que o IP é dispensável, gozando o MP do prazo de 15 dias da correspondente provocação (art. 46, CPP).

iii) Juiz (das garantias)

Obs. Postura:

- requisitar a instauração de IP (art. 5º, II, CPP);
- abrir vistas ao MP, desde do respeito ao sistema acusatório.

b.2) Legitimidade ATIVA (classificação):

b.2.1) Notícia crime DIRETA/ COGNIÇÃO IMEDIATA: é aquela atribuída a atuação das Forças Policiais ou ao papel da imprensa.

Obs. Notícia apócrifa/ inqualificada- é o que rotulamos de notícia anônima.

Conclusão: diante do anonimato, não cabe a imediata instauração do IP. Primeiro, deve o delegado aferir a plausibilidade e pertinência, para só então, se for o caso, instaurar a investigação (STF. HC 97.197, Inf. 565).

Conclusão.2. Ganha destaque a verificação prévia da informação (VPI).

b.2.2) Notícia crime INDIRETA/COGNIÇÃO MEDIATA- é aquela apresentada por sujeito que não integra as forças policiais, mas que está devidamente identificado.

Obs. Hipóteses:

i) Vítima/ representante legal- neste caso, a notícia é feita por meio de REQUERIMENTO.

Conclusão1. Diante da negativa de instauração, caberá recurso administrativo ao chefe de polícia (art. 5º, § 2º, CPP).

Conclusão2. Nos crimes de AÇÃO PRIVADA e de AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, a instauração do IP dependerá de manifestação de vontade do legítimo interessado (art. 5º, §§ 4º e 5º, CPP).

ii) MP/juiz- a notícia é formulada por meio de REQUISIÇÃO, cabendo ao delegado promover o atendimento, mesmo inexistindo vínculo hierárquico (art. 5º, II, CPP).

iii) Qualquer pessoa do povo- a notícia é feita por meio de “delação”.

Conclusão: ela é aplicável aos crimes de ação pública INCONDICIONADA (art. 5º, § 3º, CPP), já que o delegado deve instaurar o IP de ofício (art. 5º, I, CPP).

Obs. Questões complementares:

i) Delatio criminis postulatória- é sinônimo de REPRESENTAÇÃO, típica dos crimes de ação pública condicionada (art. 5º, § 4º, CPP).

ii) Delatio criminis com força coercitiva- é a notícia decorrente da prisão em FLAGRANTE, podendo ser DIRETA ou INDIRETA, a depender de quem promover a captura (art. 301, CPP).

10.2- 2º ETAPA- EVOLUÇÃO- o IP vai evoluir por meio do cumprimento de DILIGÊNCIAS realizadas de forma discricionária.

Obs. Os arts. 6º e 7º do CPP, de forma NÃO EXAUSTIVA, apontam diligências que podem ou devem ser realizadas, na melhor condução da investigação.

10.3- 3º ETAPA- ENCERRAMENTO- o IP é encerrado por meio de um RELATÓRIO.

a) Conceito: é a peça descritiva que vai destacar as diligências realizadas e eventualmente justificar as que não foram feitas, mas que eram pertinentes (art. 10, §§ 1º e 2º, CPP).

b) Lei de Drogas- de acordo com LFG, temos uma certa mitigação na Lei de Drogas sobre a questão da descritividade do relatório, já que o delegado deve apontar as razões de enquadramento no tráfico e não no porte para uso (art. 52, I, Lei 11.343/06).

Conclusão: de acordo com o STF (RE 635.659), temos presunção relativa de por para uso de até 40 g de maconha.

Conclusão2. Em tal contexto, temos um indiferente penal, tratando-se de ilícito administrativo.

10.4- Desdobramento do procedimento:

a) Autos do IP com o RELATÓRIO.

b) Caberá a remessa ao JUIZ (art. 23, CPP).

Obs.1. Essa remessa será ao juiz das garantias, nas localidades onde exista a adequada implementação (art. 3º-B, CPP).

Obs.2. O STF já declarou a inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais regulando a tramitação direta do IP entre o delegado e o MP.

Obs.3. A Resolução 63 do CJF é objeto de ADI perante o STF, questionando-se a tramitação direta do IP.

Obs.4. De acordo com a DOUTRINA majoritária, o DESTINATÁRIO do IP é o titular da ação penal, sendo o detentor da opinião delitiva.

c) Cabe ao juiz abrir vistas ao MP

d) Diante do IP, o MP terá as seguintes alternativas:

d.1) 1º alternativa: diante da presença de indícios de autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração, caberá o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA (petição inicial pública), com o objetivo de que seja deflagrado o processo (art. 24, CPP).

Obs.1. Se a denúncia é amparada no IP, ele deve acompanhar a inicial (art. 12, CPP), bem como os instrumentos do crime (art. 11, CPP).

Obs.2. De acordo com o STF, no julgamento das ADI's 6298, 6299 6305, a competência do juiz das garantias cessa com o OFERECIMENTO da inicial acusatória.

Obs.3. Acordo de NÃO PERSECUÇÃO PENAL- nos crimes com PENA MÍNIMA inferior a 4 anos, praticados sem violência ou grave ameaça e fora do contexto da violência doméstica, caberá a proposta de medida alternativa, com a confissão circunstanciada do fato, redundando na extinção da pubibilidade, após a adimplimento integral da condições (art. 28-A, CPP).

Conclusão: temos aqui a justiça penal negociada.

d.2) 2º alternativa- diante da fragilidade do lastro indiciário, é possível que exista ESPERANÇA da imediata obtenção. Logo, caberá o requerimento de diligências complementares consideradas imprescindíveis ao início do processo (art. 16, CPP).

Obs. O magistrado não deve indeferir a remessa da diligência pretendida para ser cumprida. Se o fizer, estará tumultuando a evolução do procedimento, em ato que desafia CORREIÇÃO PARCIAL.

d.3) 3º alternativa- inexistindo viabilidade ára o início do processo, caberá o arquivamento da investigação.

d.3.1) Procedimento ANTES DO PACOTE ANTICRIME- com a original redação do art. 28 do CPP, caberia ao membro do MP requerer o arquivamento ao JUIZ, podendo este assumir as seguintes posturas:

i) Se o juiz concordasse, caberia a ele HOMOLOGAR A PRETENSÃO.

Conclusão: percebe-se que a o arquivamento era feito pelo juiz, pressupondo requerimento do MP.

ii) Diante da discordância do magistrado, caberia a ele remeter os autos ao PG do MP, para assim proceder:

ii.1) Oferecer ele próprio DENÚNCIA;

ii.2) Designar outro membro do MP para denunciar, que atuaria por delegação (longa manus) do PG;

ii.3) Insistir no arquivamento, cabendo ao juiz homologar.

ADVERTÊNCIA: ao acionar o PG, o juiz desempenhava função anômala de FISCAL DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PÚBLICA, questionando-se o respeito ao sistema acusatório.

d.3.2) Procedimento APÓS O PACOTE ANTICRIME- com a atual redação do art. 28 do CPP, caberá ao membro do MP ordenar o arquivamento, o submetendo à instância de revisão para homologação, comunicando ao delegado, ao ofendido e ao investigado.

Obs.1. A vítima desfruta do prazo de 30 dias contados de sua intimação para apresentar recurso administrativo à instância de revisão do MP.

Obs.2. Na esfera federal, a instância de revisão é exercida pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Obs.3. Em crimes contra a União, estados ou Municípios, a revisão pode ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação jurídica (§2º, art. 28, CPP).

Obs.4. Interpretação do STF- de acordo com a Suprema Corte, firmando tese, cabe ao membro do MP submeter o arquivamento ao JUIZ (das garantias). Caso o magistrado entenda que existe teratologia ou ilegalidade, poderá provocar a instância de revisão do MP, aplicando-se o § 1º do art. 28 do CPP.

11- Questões COMPLEMENTARES:

a) Consequência do arquivamento- de acordo com a Súmula 524 do STF, o arquivamento do IP, de regra, não faz coisa julgada material. Logo, surgindo NOVAS PROVAS, antes da extinção da punibilidade, caberá o oferecimento da denúncia.

Obs.1. Logo, o arquivamento segue a cláusula “rebus sic stantibus” (como as coisas estão).

Obs.2. Natureza jurídica das PROVAS NOVAS- são consideradas CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.

Obs.3. Classificação das provas novas:

i) Prova SUBSTANCIALMENTE nova- é a prova inédita, desconhecida no momento do arquivamento.

ii) Prova FORMALMENTE nova- é aquela já conhecida, mas que ganhou NOVA VERSÃO.

ADVERTÊNCIA: ambas podem justificar a oferta da denúncia.

b) Definitividade do arquivamento- de acordo com o STF, o arquivamento é apto à imutabilidade pela COISA JULGADA MATERIAL quando amparado na CERTEZA da atipicidade (formal ou material), bem como na certeza da extinção da punibilidade.

Obs. De acordo com a POSIÇÃO MAJORITÁRIA, as excludentes de ilicitude e culpabilidade justificando o arquivamento, não fazem coisa julgada material.

c) Papel da polícia- de acordo com o art. 18 do CPP, a polícia poderá realizar diligências com o objetivo de colher PROVA NOVA que viabilize a oferta da denúncia.

ADVERTÊNCIA: vale lembrar que o DESARQUIVAMENTO DO IP é papel funcional do MP.

d) TCO (termo circunstanciado de ocorrência)- é o registro simplificado das IMPO, leia-se, crimes com pena de até 2 anos, bem como contravenções penais, sendo remetido de imediato ao juizado especial criminal (art. 69, Lei 9099/95).

Obs. De acordo com o STF (ADI 5637), o TCO não tem natureza de procedimento investigativo, podendo ser elaborado pela PM e pela Polícia Rodoviária (ADI's 6245 e 6264).

e) Arquivamento ORIGINÁRIO- é aquele promovido diretamente pelo PG do MP, nas hipóteses de sua atribuição originária.

f) Arquivamento IMPLÍCITO- de acordo com Afrânio Jardim, tal instituto permite que o juiz provoque a instância de revisão do MP, ao perceber que a denúncia não contemplou todos os sujeitos e/ou crimes trazidos no IP.

Obs.1. Classificação:

i) Arquivamento implícito OBJETIVO- ele ocorre quando a omissão é de CRIMES.

ii) Arquivamento implícito SUBJETIVO- ele ocorre quando a omissão é de sujeitos que foram indiciados, mas não foram denunciados.

Obs.2. Filtro- de acordo com o STF, o instituto não possui regulação em lei, devendo ser afastado.

AÇÃO PENAL

1- Conceito: é o DIREITO público e subjetivo com previsão constitucional de exigir do Estado- juiz a aplicação da lei ao caso concreto, para a solução da demanda penal.

Obs. Já o processo é um procedimento em contraditório animado pela relação entre os sujeitos processuais.

2- Modalidades de ação penal- levamos em consideração a INICIATIVA para a propositura da demanda, vejamos:

2.1- Ação penal de INICIATIVA pública

2.2- Ação penal de INICIATIVA privada

ADVERTÊNCIA: de acordo com Hélio Bastos Tornaghi, toda ação penal ontologicamente é PÚBLICA, em razão da qualidade dos interesses versados. O que oscila é a INICIATIVA para a propositura da demanda.

3- Ação penal de INICIATIVA pública

3.1- Conceito: é aquela titularizada PRIVATIVAMENTE pelo MP, de acordo com o art. 129, I, CF (pilar do sistema acusatório), bem como ao art. 257, I, CPP.

Obs.1. O sistema acusatório tem como grande vetorial a separação de funções, sendo explicitado no art. 3-A do CPP.

Obs.2. Processo judicialiforme- era a possibilidade de juízes e delegados exercerem a ação pública, sem intervenção do MP.

Conclusão: resta constatar que o art. 26 do CPP NÃO FOI RECEPCIONADO pelo art. 129, I, CF.

Obs.3. A inicial acusatória é a DENÚNCIA, sendo que os seus requisitos formais estão no art. 41 do CPP.

3.2- Princípios

3.2.1- Princípio da OBRIGATORIEDADE

I- Conceito: o exercício da ação de iniciativa pública é um DEVER FUNCIONAL inerente a atuação do MP.

Conclusão: percebe-se pelo art. 24 do CPP o dever de atuação do MP.

II- Princípio da obrigatoriedade mitigada/ princípio da discricionariedade regrada- de acordo com parte da doutrina, o princípio da obrigatoriedade admite mitigação por meio de institutos da justiça penal negociada, vejamos:

II.1- Transação penal (art. 76, Lei 9099/95);

II.2- Colaboração premiada (art. 4º, Lei 12.850/013);

II.3- Acordo de não persecução penal (ANPP)- art. 28-A, CPP.

ADVERTÊNCIA: para Afrânio Silva Jardim, é atecnico falarmos em mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Afinal, em um sistema regido por tal princípio, a antítese é a oportunidade, regulada eventualmente em lei.

3.2.2- Princípio da INDISPONIBILIDADE